



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0087128-49.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **PATRICIA DA ROCHA DOS SANTOS e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Erica Regina Colmenero Coimbra**

Vistos.

PATRÍCIA DA ROCHA DOS SANTOS e DANIELE DE OLIVEIRA LEITE, devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, foram denunciadas como incursoas no artigo 33, *caput*, e no artigo 35, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 69 do Código Penal, sob a acusação de, no dia 17 de outubro de 2016, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que na data de 17 de outubro de 2016, por volta das 18hs40min, na Rua Walter Wey, altura do nº 99, no bairro do Parque Pereria, nesta comarca de São Paulo, as acusadas, já qualificadas, foram surpreendidas quando transportavam, para fins de comércio ou entrega a consumo de terceiros, 1.600 (um mil e seiscentos) microtubos de plástico, tipo “eppendorf”, contendo aproximadamente, 1.337 g (um mil e trezentas e trinta e sete gramas) de cocaína, 450 (quatorcentos e cinquenta) microtubos de plástico, tipo “eppendorf”, contendo, aproximadamente, 1.039g (um mil e trinta e nove gramas) de cocaína, 500 (quinhentos) microtubos de plástico, tipo “eppendorf”, contendo, aproximadamente, 416g (quatrocentos e dezesseis gramas) de cocaína, e 4.000 (quatro mil) invólucros de papel alumínio retorcido, contendo, aproximadamente, 905g (novecentas e cinco gramas) de cocaína, na forma popularmente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

conhecida como crack, substâncias, estas entorpecentes, que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi determinada a notificação das acusados no dia 22 de novembro de 2016 (fls. 181/183) para apresentação de Defesa Prévia, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de janeiro de 2017, bem como indeferiu-se o pedido de revogação da prisão preventiva das acusadas, ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

A denúncia foi devidamente recebida e, confirmada a audiência de instrução, debates e julgamento para a data já reservada foi devidamente realizada. Foram interrogadas as corréis e, diante da ausência das testemunhas de acusação e insistência em sua oitiva por parte da acusação foi designada nova audiência para o dia 22 de março de 2017. Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas faltantes, sendo encerrada a instrução e aberto prazo para apresentação de memoriais escritos.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A defesa da acusada Daniele, por seu turno, pugnou pela absolvição da ré ante a ausência de provas para ambos crimes a ela imputados, impugnando o depoimento dos policiais ouvidos em juízo. No mais, indica a inexistência do crime de associação para o tráfico dada ausência de habitualidade na conduta da ré, informando que esta teria se dado em razão de inexigibilidade de conduta diversa. Em teses subsidiárias pugna pela fixação da pena base em seu mínimo legal; pela aplicação do regime inicial aberto; a aplicação da causa de diminuição trazida pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo; e pela eventual substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. A defesa da acusada Patrícia, pleiteou a absolvição por insuficiência do conjunto probatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal bem como a inexistência do crime de associação para o tráfico. Requereu em teses subsidiárias a fixação da pena base em seu mínimo legal; a aplicação da atenuante da confissão; a fixação de regime inicial menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, em seu patamar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

máximo, bem como que seja facultado à acusada o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada **parcialmente procedente**.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/11), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/18), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 19/20), pelos laudos periciais (fls. 237/239 e 243/245), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A ré **DANIELLE**, ouvida em Juízo, confessa que recebeu aquela mochila. Sabia que era algo ilícito que continha em seu interior. Conhecia a corré da região em que morava. Um colega de nome Felipe ofereceu a ela R\$ 600,00 para entregar a droga até outra pessoa. Iria deixar a mochila para uma pessoa em um ponto de ônibus. Não conhecia os policiais que a abordaram. Trabalhava como atendente em uma lanchonete. Aceitou, pois necessitava do dinheiro para comprar um medicamento. Nunca tinha feito isso outra vez tampouco foi processada anteriormente.

A ré **PATRÍCIA**, ouvida em Juízo, havia acabado de dar a luz. Estava precisando de dinheiro. Fazia o serviço há uma semana. Havia recebido seiscentos reais naquela semana. Transportava algo que sabia ser ilícito, mas não sabia que se tratava de entorpecentes. Nunca foi processada. Não conhecia os policiais que a detiveram.

A testemunha Policial Civil **CÉSAR PAULO GAZDA**, ouvida em Juízo, afirmou que trabalhava na DISE de Santo André. Em um inquério policial foi apurado, através de interceptação telefônica regular, que a droga que seria revendida em S. André viria de S. Paulo. Um dos telefones interceptados foi o da corré Patrícia. Soube-se que ela pegava as drogas nos locais em que eram embaladas e era responsável por levar o entorpecente até um outro ponto para ser revendida. No dia, através da interceptação telefônica, pelas ERBs acionadas foi possível saber onde Patrícia estava. No momento da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

abordagem, Patrícia e Daniele estavam juntas, cada uma com uma mochila. No interior das mochilas havia enorme quantidade de cocaína e crack. As rés não levavam dinheiro. Ao serem abordadas, as rés confessaram que transportavam drogas e que recebiam seiscentos reais por semana para realizar a prática. Não as conhecia de outras ocorrências policiais. Às perguntas da acusação respondeu que não conhecia as corrés de outras abordagens, mas apenas sabia da identidade delas em razão das interceptações telefônicas realizadas. Às perguntas da defesa de Danielle, respondeu que com as corrés não foi encontrado qualquer valor em dinheiro.

A testemunha **CARLOS ALBERTO DE SOUZA**, ouvido em Juízo, reconhece as rés. Participou apenas das diligências de campo relacionadas à corrê Patrícia. Soube que ela estava sendo monitorada através de interceptação telefônica. Em determinado momento da investigação foi pedido pelo policial César que o depoente acompanhasse as diligências em relação a corrê Patrícia, para saber onde ela ia e descobrir onde os entorpecentes estariam armazenados. Em uma das diligências o depoente seguiu Patrícia até uma comunidade. Passados alguns dias viu Patrícia com uma outra moça, que o depoente não sabe confirmar que seja a corrê, pois estava a certa distância, entrando em uma comunidade e sempre portando uma mochila consigo. Continuaram seguindo Patrícia, mas a perderam de vista quando ela entrou na favela. Após voltar a encontra-la, realizaram a abordagem das corrés que estavam juntas. Cada uma tinha uma mochila consigo. Com Patrícia foram encontradas mais de dois mil porções de cocaína; com Daniela, por volta de 500 de cocaína e 4000 porções de crack. Elas confesarm que pegaram os entorepecentes na comunidade e que recebiam seiscentos reais por semana para realizar o transporte. Não foi possível identificar o local onde as corrés retiraram as drogas, dentro da comunidade. Às perguntas da acusação respondeu que Adilson participou apenas da abordagem das corrés.

Diante do conjunto probatório e dos depoimentos colhidos em Juízo, possível afirmar que as provas dos autos demonstraram inequivocamente que as acusadas cometeram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Neste particular, saliente-se que, gozam os policiais dos “adjetivos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

atribuíveis à autêntica testemunha”, presumindo-se a legitimidade dos atos que, enquanto servidores públicos, praticam no exercício de suas funções.

Assim, tratando-se de presunção relativa, à defesa cumpria afastar a veracidade de tais depoimentos, demonstrando sua dissonância no tocante ao contexto probatório ou o particular interesse dos policiais na solução da causa. A propósito: “*PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE*”. 1. *Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.* 2. *Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações*. 3. *Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual.* 4. *Habeas corpus não conhecido*”. (STJ: HC 206282 SP 2011/0105418-9. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO – T6 Sexta Turma. Dje: 26/05/2015).

Vale ressaltar que os policiais ouvidos em juízo, indicaram que já possuíam a informação de que a corré Patrícia estaria envolvida com o tráfico de drogas, em razão de investigações anteriores. Tinham ciência também, que a Patrícia desempenhava papel de “mula” (transportava droga em troca de dinheiro). Nesse contexto, afirmaram que foram feitas campanas, para observação da Patrícia, sendo que puderam observar que a ela se dirigia, a uma comunidade (em que se suspeitava haver comercialização/armazenamento de entorpecentes). Relataram, ainda, que no dia em que realizaram a prisão em flagrante, Patrícia teria agido da mesma maneira: entrado na



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

comunidade com uma mochila e saindo dela tempo depois. Assim, no dia em questão, aguardaram Patrícia sair da comunidade para que pudesse ser abordada. Constatou-se que ela estava acompanhada da corré Danielle, sendo que ambas portavam mochilas. Dentro das mochilas de cada uma delas, foi encontrada grande quantidade de drogas.

Vale ressaltar que em tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, as corrés confessaram que recebiam certo valor em dinheiro para realizar o transporte de drogas, confirmando assim a versão apresentada pelos policiais em Juízo.

Logo os depoimentos uníssomos dos policiais, somados à confissão de ambas corrés formam prova concreta e inequívoca de que ambas praticaram o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia. Assim, o elemento subjetivo do tipo consubstanciado no dolo restou comprovado. A absolvição alvitada pela defesa é inviável. A prova é sólida e autoriza o decreto condenatório. Os depoimentos dos policiais, bem como todo o contexto em que os fatos se deram, evidenciam a ocorrência do crime. A intenção de tráfico se verifica, ainda, pela quantidade de droga encontrada em poder de cada uma das corrés e sua forma de acondicionamento, o que comprova que a droga era destinada ao comércio. Logo, de rigor a condenação.

Acerca da possível associação entre as acusadas para venda de entorpecentes, entendo que a mesma não restou demonstrada nos autos. Nesse ponto, é de suma importância notar que não há provas concretas que sejam hábeis a comprovar o *animus associativo* entre elas.

Ora, ainda que possível a hipótese de associação entre as corrés, com a finalidade de cometer o crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há nos autos provas contundentes necessárias a embasar uma condenação por um delito de tamanha gravidade, sendo que a prudência aqui recomenda a aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Com efeito, são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

Portanto, se ausente um destes requisitos, resta configurada uma associação momentânea, regulada na lei penal como concurso de pessoas, tratando-se de uma causa especial de aumento da pena e não um delito autônomo.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos de sua definição. Neste sentido preleciona Vicente Greco Filho: *"Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..."* (GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção - Repressão: Comentários à Lei nº 10.409/2002 e à parte em vigor da Lei nº 6.368/76 - 12ª ed. Atual. - São Paulo - Editora Saraiva - 2006 - p. 127).

Portanto, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja um *animus associativo*, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris* em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico.

Na espécie, inexistem elementos sólidos a embasar o édito condenatório, não há como reconhecer, *in casu*, o delito de associação, pois meros indícios ou presunções não são suficientes para esse mister, notadamente no que diz respeito ao *animus associativo*, que por ser figura central do tipo penal do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, deve restar indubitavelmente comprovado, já que o simples concurso não é o bastante para essa finalidade. Sobre o assunto trago à colação os seguintes julgados:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recursos defensivos buscando a absolvição por falta de provas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação apenas pelo delito de tráfico de entorpecentes. Não comprovação do animus associativo prévio, com estabilidade e permanência. Mero concurso de agentes. Absolvição pelo crime de associação decretada. Ré Jennifer primária. Confissão que não pode reduzir as penas para alguém do mínimo legal. Súmula nº 213 do C. STJ. Réu Wellington reincidente. Pleito subsidiário de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Não acolhimento. Natureza, quantidade de drogas e circunstâncias do caso concreto indicando que a ré se dedicava a essa atividade criminosa. Quantum da pena que inviabiliza a substituição por sanções restritivas de direitos. Regime inicial fechado mantido. Recursos parcialmente providos. Com determinação. (TJSP: APL 00430331020138260576 SP. Relator: Sérgio Coelho - 9ª Câmara de Direito Criminal. DJe: 01/07/2015).

Assim, entende-se que não há provas sólidas hábeis a comprovar a associação entre as acusadas ou entre elas e terceiros, apesar dos relatos trazidos em juízo referentes às investigações.

Noutro giro, faz-se necessário afastar a tese defensiva aventada pela defesa da corré Daniele, que indicou que a habitualidade para configurar o vínculo associativo, no crime de associação para o tráfico, não se mostrava concretizado em razão da corré ter praticado o crime maneira isolada, e acobertada pela impossibilidade agir de forma diversa. Afirmar a defesa que a ré teria praticado tal praticado a conduta, por estar passando necessidades financeiras, e assim, tal questão deveria ser considerada.

É sabido que a jurisprudência é uníssona ao indicar a inviabilidade de se utilizar tal causa excludente de ilicitude como justificativa salvaguarda para a prática de crimes. Nesse sentido: *“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – ESTADO DE NECESSIDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME, DO VALOR DA MULTA OU SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIVERSIDADE DE DROGAS, PRISÃO EM FRAGRANTE E CONFISSÃO – A POBREZA NÃO É JUSTIFICATIVA PARA SE ESCUSAR DO CRIME –*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

PENA DOSADA COM CRITÉRIO, NO MÍNIMO LEGAL – REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO – RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP: APL 00045964420148260161 SP. Relator: Euvaldo Chaib – 6º Câmara Criminal Extraordinária. Dje:15/09/2015)

Ademais, não há prova concreta da necessidade pela qual a corré passava, que possa ensejar mínima consideração. Dessa forma, resta afastada tal questão.

Assim, reconhecidas autoria e materialidade do crime de tráfico de substâncias entorpecentes imputados às acusadas **PATRÍCIA DA ROCHA DOS SANTOS e DANIELE DE OLIVEIRA LEITE**, o decreto condenatório é medida que se impõe. Atendendo ao **método trifásico de aplicação da pena**, passo a fixá-la.

Na **primeira fase** da dosimetria da pena, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, considerando que as réus são primárias e todas as demais circunstâncias judiciais mostram-se comuns a tipo penal analisado, salvo a quantidade de drogas apreendidas.

Na **segunda fase** de individualização da pena, verifico não há agravantes a serem consideradas. Resta prejudicada a aplicação da atenuante referente à confissão, haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na **terceira fase** não há causas de aumento de pena a ser aplicada. Tampouco há que se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, considerando a grande quantidade de droga encontrada e tipo “cocaína/crack”, havendo de se concluir inequivocamente que integram organização criminosa e se dediquem às atividades ilícitas. Resta inalterada a pena acima fixada.

Entendo que o **regime mais adequado** ao cumprimento da reprimenda corporal seja o **fechado**, haja vista a gravidade dos crimes que colocam em perigo a vida e a saúde pública, não se podendo falar, ainda, em substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, em casos como o trazido a julgamento, relativamente ao crime equiparado a hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes. Explico.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa **empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo**, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos.

Na sequência o Senado Federal, através da **Resolução n.º 5/12**, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão “*vedada a conversão em penas restritivas de direitos*”, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Em 10/05/2012 a Suprema Corte também declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão e liberdade provisória, contida no caput do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, passando a admitir a concessão de liberdade provisória aos acusados da prática dos crimes de tráfico, salvo quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (HC n.º 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli).

Desta forma, é de se concluir que, embora tenha havido um “*esvaziamento*” na legislação pertinente que impunha maior repressão estatal aos crimes hediondos, é de se ressaltar, com base nos julgados acima que competirá sempre ao Magistrado definir, baseado em “**empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo**”, o regime inicial de cumprimento de pena ao qual estará sujeito o acusado, em total aplicação da previsão constitucional de individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal). No caso nos autos, analisando as circunstâncias objetivas da infração cometida, entendo que não seja o caso de fixar regime menos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

gravoso, embora a pena aplicada permita, objetivamente, referida fixação, nos termos do artigo 33, e incisos, do Código Penal. Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo, sendo de extrema gravidade, gerando consequências deletérias às famílias de dependentes químicos, bem como de toda a sociedade, pois o tráfico ilícito de entorpecentes é a mola propulsora de diversos crimes, em especial aqueles contra o patrimônio, tais como furtos, roubos, extorsões e latrocínios.

Ademais, o tráfico de drogas objetiva, quase sempre crianças e adolescentes, os quais ainda possuem personalidade em formação, acarretando, conseqüentemente, desestruturação de toda uma geração, em evidente prejuízo ao progresso e desenvolvimento sociais. Aliás, deve ser ressaltado que, o simples fato de se aplicar o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 não implica, inexoravelmente, em direito subjetivo do acusado à fixação de regime menos gravoso, o qual se dá nos termos já esposados, em cotejo com o disposto no artigo 59 do Código Penal (*“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”*) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (*“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”*). A propósito, nesse sentido a jurisprudência, destacando-se que o segundo argumento continua plenamente válido, *in verbis*: *“No concernente ao regime prisional impositivo à espécie, também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei nº 11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o recrudesimento da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da instituição familiar”* (TJSP, Apelação nº 0011111-87.2008.8.26.0361, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel: Des. Paulo Rossi, j. 1º/07/2009, grifei).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Portanto, no caso dos autos, em obediência ao princípio da individualização da pena, entendo não haver outro regime adequado ao início de cumprimento da reprimenda corporal que não o **REGIME INICIAL FECHADO**, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea *a*, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos já alinhavados, entendo não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, por entender que a substituição pretendida não é suficiente e eficaz à repressão do delito cometido, nos termos do inciso III do mencionado artigo.

Entendo, ainda, inaplicável, pela mesma razão, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal.

Diante do exposto, **julgo parcialmente procedente** a pretensão punitiva estatal para o fim de **condenar PATRÍCIA DA ROCHA DOS SANTOS e DANIELE DE OLIVEIRA LEITE**, qualificadas nos autos, como **incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**. Em consequência, **condeno-as a cumprir, em estabelecimento penal adequado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal, ausente notícia de fortuna das corrés; bem como para ABSOLVÊ-LAS da acusação de cometimento do delito descrito no art. 35, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal**. Conforme fundamentado acima, deverá iniciar o cumprimento das penas em **regime fechado**. Daniele respondeu ao processo presa, com mais razão, que após decreto condenatório, seja assim mantida, motivo pelo qual nego o apelo em liberdade. Ademais, ainda persistem os elementos ensejadores da decretação da prisão preventiva, haja vista que, caso seja solta, poderá vir a tentar frustrar a execução da pena, evadindo-se do distrito da culpa. Recomende-se a ré no estabelecimento prisional em que se encontra. Noutro giro, Patrícia encontra-se em liberdade (concedida via *habeas corpus*), de modo que não se mostram presentes os requisitos que autorizem sua prisão. Desse modo concedo a ela o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em caso de recurso, EXPEÇA-SE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA, com urgência.

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe.

Custas *ex lege*.

P.I.C.

São Paulo, 05 de junho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**